

1500533-06.2020.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico

A materialidade da conduta imputada aos réus encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500533-06.2020.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500533-06.2020.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2163126/2020 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 12251641 -

DEL.POL.CAPÃO BONITO, 982/20/414 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2163126 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2163126 - DEL.POL.GUAPIARA, 982/20/414 - DEL.POL.GUAPIARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMARIO RAFAEL TEIXEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de ALISSON FERNANDO DA COSTA, ROMARIO RAFAEL TEIXEIRA e EDIRLEIA DE OLIVEIRA ROSA, já devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta na denúncia (fls. 129-131), no dia 06 de julho de 2020, por volta de 03:39 horas, na Rua Brasil, nº 15, Vila Izabel, na cidade de Guapiara, nesta comarca, ALISSON, ROMARIO e EDIRLEIA, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios, transportavam drogas, consistentes em uma pedra de "crack", pesando 317,17 gramas e um invólucro contendo cocaína, com peso de 96,15 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Ministério Público, na data dos fatos, os réus transportavam as drogas acima descritas, com a manifesta intenção de entregá-las ao consumo de terceiros. ROMARIO estava na condução do automóvel VM/Gol, placas BPG-7265, pela referida via pública, sendo certo que os demais se encontravam no veículo. Ocorre que policiais militares que faziam patrulhamento de rotina notaram que ALISSON se mostrou assustado ao notar a aproximação da viatura policial, razão pela qual resolveram abordá-los.

Em revista pessoal, somente foi encontrada a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie e um telefone celular, os quais estavam, respectivamente, em poder ALISSON e ROMARIO. Todavia, durante vistoria realizada no veículo foram localizados os entorpecentes acima descritos, os quais os réus confirmaram que se destinavam ao comércio ilícito.

Diante das circunstâncias da prisão e da quantidade de drogas apreendida não resta dúvida de que os entorpecentes se destinavam ao tráfico de drogas.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 132-134, seguindo-se a regular citação dos réus (fls. 149, 151 e 165), com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 157-158, 159-160 e 161-162).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa...

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico

A materialidade da conduta imputada aos réus encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição e apreensão (fls. 05-06), auto de constatação preliminar (fls. 07-10), laudo de exame químico-toxicológico definitivo positivo para cocaína (fls. 167-170 e 171-174) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que os réus, foram presos em flagrante delito (fl. 01).

O réu ALISSON, na fase policial disse que: na data dos fatos, por volta das 19:00 horas o interrogando foi juntamente com ROMARIO e sua amásia EDIRLEIA para a cidade de Sorocaba, no veículo Gol de propriedade de ROMARIO, para compras drogas, tendo o "cara" as trazido na rodoviária; comprou 100 gramas de cocaína e meia peça de crack, pagando o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, a vista; tinha este valor em dinheiro, pois trabalhava de servente de pedreiro; Que ROMARIO e EDIRLEIA sabiam que o interrogando iria comprar drogas; pagou para ROMARIO a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) para ir a Sorocaba buscar a droga; o interrogando pagou também a gasolina e os pedágios, abastecendo em Capão Bonito e Itapetininga, gastando quase R\$ 200,00 (duzentos reais) em gasolina e R\$ 100,00 (cem Reais) em pedágio; iria vender a droga, e dava para tirar uns R\$ 15.000,00 (quinze mil reais); iria começar a vender drogas agora; conhece ROMARIO e EDIRLEIA faz tempo da

rua. (fls. 13-14)

Interrogado em juízo, disse que: confessa os fatos; estavam voltando de Sorocaba onde foram buscar os entorpecentes; a polícia os enquadrou; chamou ROMÁRIO por ter amizade com ele; EDIRLEIA apareceu na hora; acredita que ela não sabia; estava trabalhando em São Paulo e quando foi mandado embora na firma "Oceane" recebeu o acerto na rescisão e resolveu comprar o entorpecente; foi a primeira vez que fez isso; não vende droga; quis começar grande e caiu; já tinha pago pelo entorpecente. A ré, EDIRLEIA, na fase policial disse que: na data dos fatos, por volta das 19:00 horas à interroganda foi juntamente com seu marido ROMÁRIO e o amigo dele ALISSON para a cidade de Sorocaba, no veículo Gol quadrado de propriedade de seu marido ROMÁRIO, para que o amigo de seu marido fosse buscar drogas; ALISSON disse que tinha o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, para comprar cocaína e crack; não estava ganhando nada e apenas foi acompanhar seu marido; não viu quando ALISSON comprou a droga e não sabe de quem; viu a droga depois que o policial tirou do carro; conhece ALISSON a pouco tempo da rua". (fls. 15-16).

Interrogada em juízo, disse que: confessa o crime; foi com eles buscar a droga e tinha ciência que iam buscar o entorpecentes; ALISSON ligou à noite, umas 19 horas, chamando para irem buscar a drogas; ALISSON disse que pagaria um tanto para ROMÁRIO para levá-lo até sorocaba; a depoente não quis ficar em casa sozinha e disse que ia também; foi de "boba"; ficou no carro e nem viu onde a droga foi pega; desceram ambos, ALISSON e ROMÁRIO; voltaram com um saco; ALISSON colocou a droga embaixo do banco; o carro e o celular estão apreendidos;

O réu ROMÁRIO, na fase policial, disse que: na data de ontem, por volta das 19:00 ou 20:00 horas o interrogando foi juntamente com ALISSON e sua amásia EDIRLEIA para a cidade de Sorocaba, no veículo Gol quadrado de sua propriedade, onde ALISSON iria comprar drogas; foram até o parque Vitória Regia, onde marca o GPS e ALISSON desceu e foi comprar a droga de um "cara" que não conhece; ALISSON desceu do carro e foi na janela do outro carro e pegou as drogas; ouviu-os falando de 100 gramas de cocaína não sabendo quanto ALISSON pagou pela droga; recebeu de ALISSON a quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para ir buscar a droga, tendo ele pago também o combustível e o pedágio para irem para Sorocaba; sua amásia EDIRLEIA sabia o que estavam indo fazer em Sorocaba; ALISSON iria vender a droga, não sabendo quanto pagou pelas drogas e quanto iria ganhar com a venda das drogas; essa foi a primeira vez que foi comprar drogas com ALISSON; conhece ALISSON há bastante tempo tendo "estudado com o irmão dele". (fls. 23-24)

Interrogado em juízo, disse que: ALISSON ligou perguntando se o réu ia buscar a droga com ele que lhe daria 300 reais; na época estava desempregado e resolveu ir; falou para a esposa e ela insistiu para ir; na volta, foram pegos pelos policiais; quando chegou, desceu do carro, porém ficou na porta, não foi até o local; viu onde ALISSON pegou a droga; encostou um outro carro na frente, ALISSON foi até o carro da frente e pegou a droga e voltou para o carro; ALISSON disse que pagou 5 mil reais; o carro é do depoente; o celular era o que o depoente usava no dia a dia; estava sem bateria mas estava funcionando; já tinha recebido os 300 reais; conhece ALISSON da cidade, por ser pequena; conheceu ALISSON por intermédio do irmão, pois estudaram juntos; foi porque usava droga; não usa o carro para fazer transporte de pessoas, apenas a família; nunca havia feito transporte de drogas;

A testemunha Gilberto Natalino de Oliveira, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: é policial militar e na data em questão, estava em patrulhamento pela cidade de Guapiara, em companhia do SD PM Welington, quando visualizaram o veículo VW/GOL, de placas BPG-7265/Guapiara/SP trafegando pela Rodovia SP- 250, observaram que o passageiro do banco traseiro ficou assustado com a presença da viatura da Polícia Militar; abordaram o veículo na Rua Brasil, 15 na Vila Izabel, Município de Guapiara/SP; em revista pessoal nos ocupantes ROMÁRIO, ALISSON e EDIRLEIA, foi localizado em poder de ALISSON o valor de R\$ 20,00 e em poder de ROMÁRIO um telefone celular; em revista ao interior do veículo, localizaram um invólucro contendo "crack" e um invólucro contendo substância com características de cocaína; indagados os indiciados sobre os entorpecentes disseram que tinham ido buscar na cidade de Sorocaba/SP; na Unidade Policial os entorpecentes foram pesados, onde a porção de crack constou o peso bruto de 371,17

gramas, e a porção de cocaína constou o peso bruto de 96,15 gramas; foi dado voz de prisão em flagrante a ROMÁRIO, ALISSON e EDIRLEIA por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo os mesmos conduzidos até a delegacia de polícia, sendo apreendido os entorpecentes, o veículo, o telefone celular e o dinheiro. (fl. 11).

Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento na área central da cidade quando se depararam com o veículo gol; causou estranheza que o passageiro do banco de trás de assustou com a viatura; fizeram acompanhamento e abordaram na rua Brasil; com ROMÁRIO encontraram um celular; com ALISSON localizaram vinte reais; no veículo, o depoente localizou no assoalho do motorista os entorpecentes; ROMÁRIO relatou que ALISSON lhe pagaria 300 para irem a Sorocaba buscar a droga; ALISSON confessou a propriedade da droga; a EDIRLEIA disse ter ciência; ROMÁRIO é conhecido apenas por ter trabalhado em comércio; quando a ALISSON já tinham recebido denúncia sobre o tráfico.

A testemunha, Wellington Rodrigues Garcia, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: é policial militar e na data em questão, estava em patrulhamento pela cidade de Guapiara, em companhia do CB PM Gilberto, quando visualizaram o veículo VW/GOL, de placas BPG- 7265/Guapiara/SP trafegando pela Rodovia SP- 250, observaram que o passageiro do banco traseiro ficou assustado com a presença da viatura da Polícia Militar, onde então foi abordado o veículo na Rua Brasil, 15 na Vila Izabel, Município de Guapiara/SP; sendo feito revista pessoal nos ocupantes ROMÁRIO, ALISSON e EDIRLEIA, sendo localizado em poder de ALISSON o valor de R\$ 20,00 e em poder de ROMÁRIO um telefone celular; fizeram revista no interior do veículo, onde localizaram um invólucro contendo "crack" e um invólucro contendo substância com características de cocaína; indagados os indiciados sobre os entorpecentes disseram que tinham ido buscar na cidade de Sorocaba/SP; ALISSON teria pagado a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil Reais) pelas drogas e que conseguiria ganhar aproximadamente R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) com a venda das drogas; na Unidade Policial os entorpecentes foram pesados, onde a porção de crack constou o peso bruto de 371,17 gramas, e a porção de cocaína constou o peso bruto de 96,15 gramas; foi dado voz de prisão em flagrante a ROMÁRIO, ALISSON e EDIRLEIA por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo os mesmos conduzidos até esta delegacia de polícia, sendo apreendido os entorpecentes, o veículo, o telefone celular e o dinheiro. (fl. 12).

Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento e avistaram o veículo; ALISSON que estava no banco traseiro ficou assustado; acompanharam até uma rua tranquila e fizeram a abordagem; na revista pessoal encontraram 20 reais com ALISSON, um celular com ROMÁRIO e nada com EDIRLEIA; no assoalho do veículo encontraram as drogas; ALISSON confirmou que a droga era dele e que tinha ido buscar em sorocaba pelo valor de 5 mil reais; ROMÁRIO confessou que sabia que tinha droga e iria receber uma quantia de 300 reais; EDIRLEIA disse que somente foi informada que iriam para sorocaba e ficou sabendo apenas quando chegaram no local que tinham ido para buscar droga; a droga estava no assoalho, embaixo do banco do motorista, totalmente visível; o celular encontrado não se recorda se estava funcionando. No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem esmeradamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP,

rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório extraído dos autos tem-se que os réus, presos em flagrante delito, confessaram que foram comprar drogas na cidade de Sorocaba, as quais revenderiam, tendo, contudo, sido interpelados pelos policiais militares.

Dos depoimentos de ALLISSON, ROMÁRIO e EDIRLEIA percebe-se que um aderiu à conduta do outro, todos cientes de que o motivo exclusivo da ida até a cidade de Sorocaba era a busca de entorpecentes.

Os réus, de forma consciente e espontânea, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios, transportavam drogas, consistentes em uma pedra de “crack”, pesando 317,17 gramas e um invólucro contendo cocaína, com peso de 96,15 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Com isso, está preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. Os réus agiram com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade das condutas, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, os réus possuem plena capacidade penal e podem ser responsabilizados por seus atos. São penalmente imputáveis e possuem condições de compreender a ilicitude de suas condutas e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuíam conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisessem de outra forma. Optaram pela conduta ilícita quando deles era exigível comportamento diverso. Por tais razões, as suas condutas são culpáveis.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu ALISSON FERNANDO DA COSTA, ROMÁRIO RAFAELTEIXEIRA e EDIRLEIA DE OLIVEIRA ROSA nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.2 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.2.1 Dosimetria da pena

a) Para o réu ALISSON

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição

do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendido cocaína e crack. Há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Crack, especialmente, apresenta potencial viciante maior, gerando com facilidade a drogadição. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerados de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício.

Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que “pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como o caso de Guapiara. Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”

Por essas razões, em razão não apenas do seu potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, o tráfico do crack deve receber reprimenda maior. Assim, considero negativa a natureza das substâncias.

Em relação à quantidade, foram apreendidas drogas consistentes em uma pedra de “crack”, pesando 317,17 gramas e um invólucro contendo cocaína, com peso de 96,15 gramas. O montante já se mostra suficiente para ensejar maior reprovação, de modo que a circunstância deve ser considerada negativa.

A experiência da prática forense permite a afirmação, após a realização de inúmeras oitivas de réus e testemunhas, que o quilo do crack custa aproximadamente 20 mil reais (o que é compatível com o valor indicado pelo réu – ele disse que pagou R\$ 5.000,00), e traficantes não ligados à criminalidade organizada ou iniciantes na mercancia das drogas raramente são encontrados com tamanha quantidade.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confira-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na

pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 8 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/8 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceram-se duas circunstâncias como negativas (a quantidade e a natureza da substância), acresço ao piso 2/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 7 anos de Reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há circunstância atenuante aplicável à hipótese, pois o agente confessou a prática do crime (artigo 65, inciso III, d, primeira parte, do Código Penal), em relação às agravantes, observa-se não constarem quaisquer das situações ou circunstâncias previstas nos arts. 61 e 62, do mesmo diploma, razão pela qual a atenuo a pena em 1/6. A pena provisória ajusta-se em 5 anos e 10 meses de Reclusão e 583 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, embora o réu seja primário, veja-se que, mesmo morando em Guapiara, manteve contato com fornecedor na cidade de Sorocaba. Ou seja, tem conhecimento aprofundado acerca das pessoas envolvidas na atividade ilícita, de modo a encontrar fornecedor em outra cidade, distante mais de 150km de onde pretendia vender os entorpecentes (Guapiara). Como apontado alhures, traficantes iniciantes raramente têm acesso a essa quantidade de entorpecente. As testemunhas indicaram já terem recebido denúncias do envolvimento de ALISSON com o tráfico de entorpecentes. Assim, tomando em consideração todas essas circunstâncias, é possível concluir pelo severo envolvimento do réu com a traficância, seu meio de vida, afastando a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Portanto, torno definitiva a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

b) Para o réu ROMÁRIO

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza e à quantidade das drogas, aplicam-se as mesmas considerações lançadas por ocasião da dosimetria do réu ALISSON (item "a", supra). Não há necessidade de repetição.

Considerando que no presente caso reconheceram-se duas circunstâncias como negativas (a quantidade e a natureza da substância), acresço ao piso 2/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 7 anos de Reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há circunstância atenuante aplicável à hipótese, pois o agente confessou a prática do crime (art. 65, inciso III, d, primeira parte, do Código Penal), em relação às agravantes, observa-se não constarem quaisquer das situações ou circunstâncias previstas nos arts. 61 e 62, do mesmo diploma, razão pela qual a atenuo a pena em 1/6. A pena provisória ajusta-se em 5 anos e 10 meses de Reclusão e 583 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, considerando o fato do réu não ser reincidente, não ter maus antecedentes e de ter ficado evidenciado que seu envolvimento deu-se com a disponibilização do veículo para o transporte da droga, jamais tendo os policiais recebido qualquer notícia quanto ao seu envolvimento com a criminalidade ou tráfico de entorpecentes, afigura-se cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 2/3. Portanto, torno definitiva a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

c) Para a ré EDIRLEIA

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza e à quantidade das drogas, aplicam-se as mesmas considerações lançadas por ocasião da dosimetria do réu ALISSON (item "a", supra). Não há necessidade de repetição.

Considerando que no presente caso reconheceram-se duas circunstâncias como negativas (a quantidade e a natureza da substância), acresço ao piso 2/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 7 anos de Reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há circunstância atenuante aplicável à hipótese, pois o agente confessou a prática do crime (art. 65, inciso III, d, primeira parte, do Código Penal), em relação às agravantes, observa-se não constarem quaisquer das situações ou circunstâncias previstas nos arts. 61 e 62, do mesmo diploma, razão pela qual a atenuo a pena em 1/6. A pena provisória ajusta-se em 5 anos e 10 meses de Reclusão e 583 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, aplicam-se os mesmos argumentos empregues na dosimetria do réu ROMÁRIO (item "b", supra). Não há necessidade de repetição. Aplico a causa de diminuição de pena do art. 3, §4º, da Lei nº. 11.343/2006 e diminuo a pena em 2/3. Portanto, torno definitiva a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

2.2.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão para ALISSON e 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão para os réus ROMÁRIO e EDIRLEIA, o fato de os réus não serem reincidentes e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente semi-aberto para ALISSON e aberto para ROMÁRIO e EDIRLEIA..

2.2.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso o réu ALISSON foi condenado a pena superior a 4 anos, não satisfazendo o requisito objetivo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por outro lado, os réus ROMÁRIO e EDIRLEIA foram condenados a penas inferiores a 4 anos. Além disso, os condenados não são reincidentes pelo que fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP).

Tendo em vista a pena fixada, determino a substituição por duas restritivas de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade (art. 44, §2º, do CP), a ser cumprida à razão de 1 hora por dia (art. 46, §3º, do CP), em entidade a ser estabelecida pelo juízo da execução, pelo prazo da condenação e prestação pecuniária de R\$ 2.000,00, a ser corrigida desde a data do fato pela tabela prática do TJSP.

2.2.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.2.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Receptação. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de

Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus:

- a) ALISSON FERNANDO DA COSTA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 583 dias-multa;
- b) ROMARIO RAFAEL TEIXEIRA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas 1 ano, 11 meses e 10 dias de Reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 194 dias-multa;
- c) EDIRLEIA DE OLIVEIRA ROSA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas 1 ano, 11 meses e 10 dias de Reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de e 194 dias-multa.

FIXO para todos os réus o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos.

SUBSTITUO a pena privativa dos réus ROMÁRIO RAFAEL TEIXEIRA e EDIRLEIA DE OLIVEIRA ROSA de liberdade por DUAS restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no valor de R\$ 2.000,00 corrigido desde a época dos fatos pela tabela prática do TJSP.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Os réus responderam ao processo em liberdade e as penas aplicadas serão cumpridas em regime diverso do fechado.

Ausentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de

Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a segregação e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Os réus poderão recorrer em liberdade.

4.2 Fixação do valor mínimo para reparação do dano

O tráfico de drogas tem como vítima toda a coletividade. Não há, portanto, dano a ser reparado.

4.3 Perdimento de bens e valores

Nos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.491, "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE 638491, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, Repercussão Geral).

O art. 60, §§ 5º e 6º, da Lei de Drogas excetua os veículos utilizados no tráfico de entorpecentes da possibilidade de restituição ao seu proprietário.

Assim sendo, DECRETO O PERDIMENTO os bens e valores apreendidos às fls. 05-06.

4.4 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intimem-se os réus para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
 - b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
 - c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
 - d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
 - e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
 - f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
- Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA